

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

甲は、高齢女性Aから同人名義のキャッシュカード（以下「カード」という。）を不正に入手するため、甲が警察官を装いAに電話をかけ、これからA方を訪れる警察官の確認を受けながらカードを封筒に入れ、同封筒をA方において保管する必要があるとそを言い、警察官に成り済ました乙（25歳、男性）がA方を訪れ、隙を見て同封筒を別の封筒とすり替えて持ち去り、カードを丙に渡して甲に届けさせる計画（以下「本件計画」という。）を考え、乙に本件計画の実行を指示し、乙はこれを承諾した。某日午前9時頃、本件計画に基づき、甲がAに電話をかけて上記うそを言い、乙は、同日午前9時15分頃、A方を訪ね、Aにカードを封筒に入れるよう求めた。しかし、乙の態度を不審に思ったAが、乙に身分証の提示を求めたので、乙は、逮捕を免れるとともに本件計画どおりにカードを手に入れるため、Aを手拳で多数回殴り、恐怖で抵抗できないAからカードを奪って持ち去った。同日午前9時20分頃、乙は、甲に電話で、本件計画どおりカードを入手したと伝えた。同日午前9時30分頃、甲は、丙に電話をかけ、本件計画の内容を初めて説明し、乙からカードを受け取って甲に届けるよう依頼し、丙はこれを承諾した。丙は、同日午前11時頃、乙と合流し、カードを受け取って乙と別れ、自動車でA方から約50キロメートル離れた甲方に向かったが、同日午後0時30分頃、甲方付近で降車した際、制服警察官BからA方での事件とは関係なく職務質問を受けた。その際、丙は、Bを殴り、Bに全治2週間を要する打撲傷を負わせ、その隙に上記自動車で逃走し、同日午後1時頃、甲と合流して甲にカードを届けた。その後、丙の交際相手丁は、丙が上記一連の犯行を行い、警察から捜査されていることを認識しつつ、丙を丁の自宅にかくまった。

【記述】

- ア. 乙がAからカードを奪った行為は、窃盗罪の実行に着手した後、Aに暴行を加えてこれを奪取したことになるから、乙に事後強盗既遂罪が成立する。
- イ. 甲が乙のAに対する暴行・脅迫を認識も予見もしていなかった場合、乙がAからカードを奪取した行為について、甲に窃盗未遂罪の共同正犯が成立するにとどまる。
- ウ. 甲は、当初から丙にカードを運搬させる計画であり、その運搬は重要な役割であるから、丙には盗品等運搬罪ではなく窃盗罪の共同正犯が成立する。
- エ. 丙がBを殴って負傷させた行為には、公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、これらは観念的競合となる。
- オ. 丙のいずれの行為についても、証拠上、犯罪の嫌疑が不十分として不起訴となった場合、丁が丙をかくまった行為について犯人蔵匿罪は成立しない。

|         |      |     |     |     |     |     |     |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No.443  | 総合事例 |     |     |     |     |     | 正答率 |
| 共通R5-20 | 正解   | ア 2 | イ 2 | ウ 2 | エ 1 | オ 2 | 29% |

## ア 誤っている

本記述は、いわゆる居直り強盗の事案である。居直り強盗とは、窃盗に着手し、又はそれ以前の段階で発見されたため、あらためて財物強取の目的で暴行又は強迫を行った場合をいい、この場合、236条の強盗罪が成立する。よって、乙には、強盗既遂罪が成立する。なお、最決令4.2.14(重判令4刑法1事件)は、本記述に類似する(ただし、被害者宅付近路上まで赴いたが、警察官の尾行に気付いて断念し、その目的を遂げなかった)事案において、「本件うそが述べられ、金融庁職員を装いすり替えによってキャッシュカードを窃取する予定の被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では、……キャッシュカードの占有を侵害するに至る危険性が明らかに認められる」として、「被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点」において実行の着手を認めている。

## イ 誤っている

最判昭 25.7.11 は、故意が異なる共犯者間に成立する犯罪について、「構成要件が重なり合う限度で軽い……共同正犯が成立する」としており、窃盗と強盗は、窃盗の限度で重なり合いが認められる(最決昭 54.4.13)ことから、窃盗罪の共謀に基づいて、実行行為を分担した者が強盗を行った場合、実行行為を分担しなかった共犯者には、共謀の限度である窃盗罪の共同正犯が成立する。本記述の甲は、乙に本件計画の実行を指示し、乙はこれを承諾していることから、窃盗罪の共謀が認められる。乙が勝手に暴行・脅迫を行ってカードを持ち去った場合、甲には、窃盗既遂罪の限度で共同正犯が成立する。したがって、甲に成立する犯罪は、窃盗未遂罪にとどまらない。

## ウ 誤っている ★

本記述の本件計画は、Aからカードを奪う部分と、奪ったカードを甲に届ける部分とに大別できるところ、本記述では、甲と乙が窃盗の共謀に基づきAからカードを奪って既遂に達した後、丙が甲からの運搬行為の依頼を承諾し、運搬しているにすぎない。よって、窃盗罪につき共同実行の意思及び共同実行の事実はなく、丙に同罪の共同正犯は成立しない。したがって、丙には窃盗罪の共同正犯は成立せず、盗品等運搬罪が成立し得るにすぎない。

## エ 正しい

大判明 42.7.1 は、公務執行妨害罪と傷害罪の罪数関係につき、観念的競合になるとしている。したがって、丙が警察官Bを殴って傷害を負わせた行為には、公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合になる。

## オ 誤っている

大判大 12.5.9 は、罰金以上の刑に当たる罪を犯したとして捜査中の犯罪人であることを知って蔵匿し又は隠匿せしめた場合は犯人蔵匿隠避罪が成立し、当該犯人が確定的犯人であることの事実及び証拠の説示を必要としないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、仮に、被疑者・被告人を本罪の対象から除外すれば、国の刑事司法作用を保護法益とする立法趣旨を大きく損なうという点を挙げている。本記述の丁は、丙が一連の犯行を行い、警察から捜査されていることを認識しつつ、丙を丁の自宅に匿っている。したがって、丁には犯人蔵匿罪が成立する。